

1500748-23.2021.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCEL PANGONI GUERRA

Comarca: Regente Feijó

Foro: Foro de Regente Feijó

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... envolvimento de adolescente em crimes como o tráfico de drogas e a associação para o tráfico, aplica-se apenas a causa de aumento prevista na Lei de Tóxicos, não se cogitando do crime de corrupção de menores, sob pena de bis in idem).

Assim já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. CAUSA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Regente Feijó

Foro de Regente Feijó

Vara Única

Rua: Carlos Beltrame, 10 - Portal do Sol

CEP: 19570-000 - Regente Feijo - SP

Telefone: (18) 3279-1555 - E-mail: regfeijo@tjisp.jus.br

1500748-23.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500748-23.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE DOS SANTOS CABRAL

CONCLUSÃO: Em 07/06/2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito desta Comarca de Regente Feijó. Eu, assistente judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCEL PANGONI GUERRA

VISTOS.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de FELIPE DOS SANTOS CABRAL, vulgo "Cabralzinho", sendo-lhe imputada a prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 02 de setembro de 2021, por volta de 17h00, na Rua Joaquim Macedo, n. 160, Bairro Nosso Teto III, nesta cidade e Comarca de Regente Feijó, o réu, agindo em comum acordo e com unidade de desígnios com a adolescente J.A.S. (d.n. 21.07.2006 - com 15 anos de idade), trazia consigo e guardava drogas consistentes em 27,75 gramas de cocaína, em forma de pedras de crack, fracionadas e acondicionadas em 29 papelotes; 35,17 gramas de cocaína, em forma de pedra de crack; e 0,56 gramas de cocaína, em forma de pedra de crack, acondicionada em um

papelote, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a entrega a consumo de terceiros (cf. autos de exibição e apreensão de fls. 17/19 e laudos periciais de fls. 111/113, 114/116).

Consta ainda que, em data incerta, mas anterior àquela supramencionada, o réu e a adolescente J.A.S. (d.n. 21.07.2006) associaram-se com o fim de praticarem, reiteradamente, tráfico de drogas nesta cidade.

Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, o réu facilitou a corrupção da adolescente J.A.S. (d.n. 21.07.2006 - com 15 anos de idade), com ela praticando as infrações penais acima descritas.

Notificado (fl. 153), o réu, através de defensor dativo (fl. 163), apresentou resposta à acusação (fls. 173/178).

A denúncia foi recebida em 28/01/2022 (fls. 186/191).

Durante a instrução houve a colheita da prova oral, tendo o réu sido interrogado (fls. 222 e 239).

Em alegações finais, o Ministério Público postulou a procedência da acusação (fls. 251/261 e 278).

Alegações finais da defesa às fls. 283/287.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória é parcialmente procedente.

A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/16), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 17/19), pelos laudos de constatação preliminar (fls. 20/23), pelos laudos periciais (fls. 111/119), bem como pela prova oral colhida em juízo, esta sob o crivo do contraditório.

Em juízo, a testemunha Amauri Aparecido Rodrigues, policial militar, narrou que no dia do fato estava em serviço no patrulhamento de força tática, no município de Regente Feijó, quando deliberaram para checar denúncia de tráfico de drogas. Que ao chegar ao endereço apontado, visualizaram o réu juntamente com a menor, esclarecendo que, quando o réu percebeu a viatura policial chegando, passou um objeto para a menor e se evadiu para os fundos do quintal. Que na abordagem junto ao réu, a princípio, foram localizados apenas R\$90,00 em espécie, tendo o acusado negado que teria drogas dentro da casa, tendo franqueado a entrada no imóvel para a verificação da denúncia. Que quando indagaram a menor acerca do que o réu teria passado para ela, verificou-se tratar de uma porção de crack embalada em um plástico azul. Expôs que foi dito para a menor o motivo da presença deles, ressaltando a existência de denúncias de tráfico contra o réu, tendo a menor confirmado de imediato que o réu estava traficando drogas naquele local. Consignou que a menor afirmou que era apenas namorada do réu e que não participava do tráfico, tendo indicado o local em que estariam as drogas na casa, que seria em um cesto de lixo da cozinha. Aduziu que na parte externa da casa foi localizada uma porção de aproximadamente 35 gramas e que, dando continuidade nas buscas, foram localizados no quarto, dentro de um colchão, R\$25,00 e 23 porções de crack embaladas para venda, assim como por volta de mais 6 pedras de crack para fracionar. Que quando o réu foi questionado sobre o tráfico, confirmou que estava praticando, dizendo que tinha acabado de sair da cadeia onde estava cumprindo pena pelo mesmo delito e que precisava de dinheiro e que havia adquirido a droga de pessoa desconhecida, pelo valor de R\$1.400,00 e que ainda seriam fracionadas para a venda. Que diante do que foi localizado na casa, foi dada voz de prisão para o réu pelo crime de tráfico, tendo havido a apreensão da menor pelo ato infracional correlato, sendo ambos conduzidos para a Delegacia de Polícia local. Disse que avistou o réu e a adolescente bem próximo - de 30/40 metros - mencionando que o acusado estava sem camisa e de bermuda, sendo o acusado o primeiro a adentrar o imóvel, pelos fundos, enquanto a adolescente ficou fora destes. Que no imóvel havia mais duas pessoas - a irmã do réu que mora na residência e outro cidadão que não recordou se era amigo ou irmão o acusado e que ditas pessoas não foram levadas à Delegacia para serem ouvidas.

A testemunha Douglas Antonio Moraes Braga, policial militar, narrou que na data do fato estava de serviço e que foram averiguar uma denúncia na qual indivíduo de nome

FELIPE, vulgo "Cabralzinho", já conhecido nos policiais estaria praticando tráfico de drogas. Que quando adentraram a rua, FELIPE foi visto junto com a adolescente J.A.S.. Que ao avistar a polícia, FELIPE passou um objeto para a adolescente e saiu correndo para os fundos/quintal da residência. Aduziu que ambos foram abordados imediatamente e que com o réu havia R\$90,00 em notas trocadas. Que ao solicitarem para a adolescente mostrar o objeto que teria recebido, constataram que se tratava de uma pedra de crack. Indagado, FELIPE negou que havia mais entorpecentes na casa. Que, porém, no quarto do casal, em meio ao colchão, foram localizados R\$25,00 reais, 23 pedras de crack já embaladas e separadas para venda, e mais 06 pedras brutas de crack, que poderiam ser fracionadas em diversas outras. Consignou que FELIPE justificou que estaria passando por necessidades financeiras e que teria acabado de sair da cadeia, em razão da prática de tráfico de drogas, tendo informado que pagou o montante de R\$1.400,00 por todas as drogas adquiridas. Que diante dos fatos, o réu e a adolescente foram levados para a Delegacia. Mencionou que, em conversa com a adolescente, ela informou que no cesto de lixo da cozinha havia uma pedra bruta, mas que não saberia informar se era de crack ou cocaína, tendo sido constatado que se tratava de cocaína. Asseverou que os policiais já conhecem o "Cabralzinho" nesse meio de tráfico de drogas. Acerca da distância que teriam sido avistados o réu e a adolescente, elucidou que foi em torno de 30 metros, confirmando que ambos estavam de frente ao imóvel. Reiterou que o réu entregou o objeto nas mãos da adolescente. Declarou que somente o réu correu, tendo a menor ficado parada de frente ao imóvel. No que tange a abordagem, explicou que os dois (réu e adolescente) foram abordados juntos, uma vez que a força tática trabalha com três policiais. Que, posteriormente, a adolescente indicou a cocaína na cesta da cozinha, tendo, em seguida, sido encontrado no quarto o restante do entorpecente. Sobre o outro policial, narrou que o trabalho é em conjunto. Não se recordou se havia outras pessoas no local. Disse que a adolescente declarou que somente era namorada do réu, não tendo participação no tráfico, tendo essa informado que o acusado estaria traficando, tendo, ainda, apontado onde haveria parte da droga na residência.

Gleice Kelly dos Santos Cabral, ouvida na condição de informante do juízo, uma vez que é ser irmã do réu, narrou que no dia do fato estava dormindo e que acordou com a presença dos policiais, que chegaram "metendo o pé no portão", porque o portão estava todo "regaçado", sendo que seus irmãos estavam no fundo do imóvel, enquanto a declarante e sua cunhada - J.A.S.- estavam na parte da frente da residência. Confirmou que os policiais conversaram com J.A.S.. Sobre as drogas, explicou que os policiais procuraram dentro da casa e que perguntaram para a adolescente se havia drogas dentro da casa e a menor disse que não, mas que depois disse que tinha. Por fim, disse que o irmão tinha parado de "mexer" com drogas e que estaria cortando cabelos. Não sabe onde J.A.S. estava quando os policiais adentraram a residência. Que quando acordou, foi atrás de seus irmãos e os viu no fundo da residência. Em seu interrogatório judicial, o réu negou a prática delitativa. Disse que no dia dos fatos estava cortando o cabelo do seu irmão quando ouviu o barulho da corrente do portão e adentrou a casa. Que, em seguida, foi abordado pelos policiais que começaram a xingar: "saí do quarto seus demônios, saí do quarto seus capetas". Explicou que dentro de um quarto estava sua mulher e que no outro estava sua irmã. Alegou que os policiais o algemaram, juntamente com seu irmão. Declarou aos policiais que não tinha nada dentro da casa, porque desde que saiu da cadeia não traficava mais drogas. Que perguntou se poderia acompanhar a revista da casa, mas não foi permitido. Que quando os policiais fizeram a revista, não encontraram nada e que chamaram o canil que também não encontrou nada. Explicou que o policial levou o cachorro para perto dele e do irmão e foi quando o cachorro "deu uma ciscada", como se tivesse algo com seu irmão, o qual foi questionado se tinha algo, mas negou, sendo que na terceira vez que o policial pediu para o seu irmão abrir a boca, achou uma "paranguinha" de maconha que estava enrolada em um plástico e que, depois disso, começaram a bater nele. Que após tal fato, os policiais colocaram a "paranguinha" de maconha no bolso do seu irmão. Explicou também que a maconha era para uso próprio e que não se recordava que a maconha estava dentro de casa, afirmando que toda vez que era abordado na rua apresentava a droga. Narrou que o

policial disse que iria “arrastar” eles e após bater no seu irmão, que se reuniram em um canto da casa e disseram que iriam levá-lo preso. Afirmou que não havia drogas dentro da casa e que os policiais só acharam a “paranguinha” de maconha. Não soube responder por que seu irmão não o acompanhou até a Delegacia, explicando que ele estava machucado depois dos policiais terem batido. Afirmou que os policiais não disseram por que ele estaria sendo preso e que a única droga que tinha era a maconha do seu irmão, tendo ciência da quantidade de droga que estava sendo apresentada quando estava chegando a Caiuá. Disse que não conhecia os policiais e que não sabe o motivo de estar sendo processado. Confirmou que a menor estava dentro do quarto quando os policiais adentraram. Não sabe se a adolescente conversou com os policiais, mas que ela ficou juntamente com sua irmã na parte da frente do imóvel, enquanto ficou com seu irmão nos fundos do imóvel. Negou que a droga fosse sua. Afirmou que quando os policiais entraram na casa, estava nos fundos pegando vassoura. Esclareceu que os policiais agrediram seu irmão, o derrubando no chão e lhe dando chutes. Que se deparou com dois policiais pela lateral do imóvel. Confirmou ter sido acionado o canil, não sabendo precisar quanto tempo levou para o canil chegar e que, ao final, havia por volta de oito policiais e duas viaturas. Que entre a primeira entrada do policiamento em sua residência e a chegada do canil decorreu por volta de meia hora e que entre a primeira abordagem policial até a ida à Delegacia demorou por volta de uma hora e meia. Afirmou que na Delegacia não lhe apontaram o motivo de estar sendo preso, reiterando que a única droga que tinha na casa era a maconha que estava com seu irmão. Que somente teve ciência da quantidade da droga quando já estava preso em Caiuá. Não se recorda de nenhum dos policiais, apenas se recordando de uma policial feminina, que estava conduzindo o cachorro na vistoria. Informou que quando o canil adentrou o imóvel, estava juntamente com seu irmão nos fundos do imóvel. Não se recorda em que estado estava o portão do imóvel. Disse que sua esposa estava o momento todo no quarto. Declarou que estava a todo momento de camiseta.

Pois bem.

Registre-se que o fato de os policiais estarem presentes quando da abordagem na situação de flagrância não implica impedimento para a tomada de seus depoimentos em juízo, sob compromisso. Nesse sentido, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Aliás, falando-se em policiais, civis ou militares, mesmo guardas civis, há de se lembrar que os seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido e inconsequente o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto, absurdo, de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas, que teriam ensejado a prisão do réu. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos, judiciais que sejam, prestados por policiais, sejam civis ou militares, mesmo guardas civis, porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada (...)” (TJ-SP – Apelação Criminal n. 3001363-88.2013.8.26.0333, Rel. Des. Airton Vieira, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, 10/12/2015).

Os depoimentos prestados pelos policiais gozam de credibilidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a verdade, a simples função por eles exercida não é de molde a ensejar o descrédito das declarações prestadas.

No caso em testilha, nada justifica o desmerecimento das versões apresentadas pelos policiais, harmônicas com outros elementos probatórios colacionados.

E não há motivo para os policiais indevidamente imputarem ao réu qualquer ilícito, tanto que o próprio acusado, em juízo, afirmou que não conhecia os policiais, ou seja, ausente qualquer desavença entre os policiais e o réu.

Conforme se depreende do arcabouço probatório amealhado, dúvidas inexistem de que o réu praticou os crimes dos artigos 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Ou seja, do arcabouço probatório amalhado, dúvidas inexistem de que o réu, na data, horário e local, descritos na denúncia, agindo em comum acordo e com unidade de desígnios com a adolescente J.A.S. (d.n. 21.07.2006 - com 15 anos de idade), trazia consigo e guardava drogas consistentes em 27,75 gramas de cocaína, em forma de pedras de crack, fracionadas e acondicionadas em 29 papelotes; 35,17 gramas de cocaína, acondicionada em uma pedra; e 0,56 gramas de cocaína, em forma de pedra de crack, acondicionada em um papelote, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a entrega a consumo de terceiros e tendo a traficância em tela envolvido a mencionada adolescente, comprovada a causa de aumento descritas no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Os autos de exibição e apreensão (fls. 17/19), laudos de constatação preliminar (fls. 20/23) e laudos periciais (fls. 111/119) corroboram terem sido apreendidas as naturezas, quantidades e formas de acondicionamento dos sobreditos entorpecentes. Ademais, a prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, confirma a sobredita prática delitiva pelo réu.

Em juízo, ambos os policiais militares foram firmes e uníssonos em aduzirem que, em patrulhamento por esta urbe, ao se dirigirem para localidade apontada como ponto de tráfico de drogas, em tal endereço visualizaram o réu na companhia da adolescente J.A.S. a quem o acusado, ao ver a viatura policial, de imediato passou um objeto para aquela e se evadiu para os fundos do quintal de sua residência, onde foi contido, tendo com ele sido encontrada a quantia de R\$ 90,00, ao passo que a menor ficou na frente do imóvel. Consta, ainda, que com a menor foi verificado que o objeto passado pelo réu se tratava de uma porção de crack, tendo a menor afirmado que o acusado estava traficando drogas naquela localidade, apontando, ademais, a existência de entorpecente no interior do imóvel do acusado - em um cesto de lixo na cozinha. Dos depoimentos dos policiais, consta também que na parte externa da casa foi localizada outra porção de entorpecente e que foram localizados no quarto, dentro de um colchão, R\$25,00 e 23 porções de crack embaladas para venda, assim como por volta de mais 6 pedras de crack para fracionar. Ambos os policiais afirmaram que o acusado lhes disse que estaria passando por necessidades financeiras e que teria acabado de sair da cadeia, em razão da prática de tráfico de drogas, tendo informado que pagou o montante de R\$1.400,00 por todas as drogas adquiridas.

As declarações de Gleice Kelly dos Santos Cabral devem ser analisadas com ressalvas, uma vez que, por ser irmã do réu, evidente que seu testemunho objetiva resguardá-lo de responsabilização penal pelos fatos em tela. Ocorre que, mesmo assim, seu depoimento se encontra isolado nos autos, no que tange à afirmação de que os policiais danificaram o portão do imóvel, o que sequer foi mencionado pelo réu. Todavia, confirmou que os policiais conversaram com a adolescente J.A.S., a qual acabou dizendo que havia droga dentro da casa. Logo, não prospera a afirmação de que seu irmão não mais estivesse traficando drogas.

Isolada nos autos a versão apresentada pelo réu em juízo, tendo sido o único a mencionar a presença do canil no local, porque nada havia sido encontrado no interior do imóvel. Além disso, isolada nos autos a versão apresentada de que somente foi encontrada maconha com seu irmão e que os policiais agrediram ele, o qual sequer foi apresentado ou compareceu na Delegacia, inclusive, na possível intenção de proteger o réu - seu irmão.

Insta consignar que, além da situação de flagrância, que permitia o ingresso do policiamento no imóvel do acusado, o policial Amauri afirmou que o réu franqueou a entrada no imóvel, não tendo o acusado, em seu interrogatório, aduzido ter negado a entrada dos policiais em sua residência.

Dessa maneira, não restam dúvidas de que o acusado praticou a traficância envolvendo a adolescente J.A.S. - 15 anos à época dos fatos (d.n. 21/07/2006 - fl. 30).

Frise-se que, ainda, procede a pretensão no tocante ao tráfico de drogas, porquanto, ao se considerar a natureza da droga, sua quantidade, bem como as circunstâncias em que se deram a apreensão do entorpecente e prisão do réu, além de seu acondicionamento e a prova testemunhal, restou demonstrada o sobredito crime. Oportuno destacar que para a caracterização do crime de tráfico de drogas não é

imprescindível a efetiva comercialização do entorpecente ou serem encontrados apetrechos utilizados para a mercancia, haja vista que tal delito já se consuma pelo fato do agente trazer consigo/guardar a droga, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Sob esse prisma, o Pretório Excelso: "A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

E eventualmente sendo o réu usuário de entorpecentes não impede a condenação pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os delitos não se confundem. A propósito, muitos viciados em drogas também são traficantes, fazendo dessa prática um meio para se obter mais recursos para a manutenção do vício.

Destarte, o cenário dos autos não deixa dúvidas de que a hipótese é sim de traficância, descabendo, indubitavelmente, cogitar-se de desclassificação para o crime descrito no artigo 28 da Lei de Tóxicos, que exige o elemento subjetivo específico de consumo pessoal do entorpecente, e não de terceiros, tal última circunstância comprovada nos autos.

Com efeito, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do entorpecente. 3. Recurso especial provido, para cassar o acórdão recorrido e, conseqüentemente, restabelecer a sentença condenatória" (STJ - 6ª Turma, REsp 1361484/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 13/06/2014).

No que concerne ao crime de associação para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 35, caput, Lei nº 11.343/06), pretensão acusatória que não procede, visto que ausentes provas robustas a embasar decreto condenatório nesse sentido.

Não comprovado o animus do réu e da adolescente em associarem-se, tampouco, em caráter duradouro e estável, com o estabelecimento de metas em comum, para o fim de comercializarem substâncias entorpecentes.

Assinala Guilherme de Souza Nucci que o elemento subjetivo do crime sub examine é o dolo. Mas, apenas o dolo genérico não basta:

"Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo art. 14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum". (NUCCI, Guilherme de Souza - Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. 1. 8ª ed. 2014).

O simples fato de o réu e a adolescente terem sido abordados conjuntamente não permite, por si só, indicar que eles se associaram para praticar o tráfico ilícito de entorpecentes e que se reuniram com o propósito de manter tal meta comum. Logo, não havendo provas incisivas da existência da firme coalização de esforços para a venda em comum de entorpecentes, assim como ausente prova do elemento subjetivo específico do tipo, de rigor a absolvição do réu em relação à imputação ora debatida.

Assim sendo, quanto à debatida imputação, a absolvição se impõe, pois:

"Dúvida que perturbe o espírito do Magistrado será a que basta a endireitar-lhe os passos para o caminho da absolvição, em obséquio ao princípio de nomeada universal: In dubio pro reo. Dúvida, em Direito Penal, equivale a ausência de prova" (Voto Nº 4.246). Daí porque, "uma condenação criminal deve apoiar-se em prova extrema de

dúvidas. Presunções e meros indícios ao ostentam qualidades de segurança e certeza, por não servirem de fundamento a decreto condenatório" (Apelação nº 660.325/7, Julgado em 22/08/1991, 1ª Câmara, Relator: Pires Neto, RJDTCRIM 11/118).

A propósito, do laudo pericial realizado no aparelho celular da adolescente (fls. 268/273 c/c fls. 274/275) não se verificou quaisquer elementos que pudessem evidenciar a prática do delito em tela ou que utilizasse do referido telefone para a prática de quaisquer outros ilícitos penais.

Consoante já aduzido, in casu, configurada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, vez que o delito de tráfico envolveu a adolescente.

Havendo delito de tráfico de drogas que envolva adolescente, de rigor a aplicação da causa de aumento referida (art. 40, inciso VI, da Lei de Tóxicos), não havendo que se falar em condenação pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), vez que estaria configurado bis in idem.

É que, na verdade, ambas as normas (causa de aumento prevista na Lei nº 11.343/06 e o delito de corrupção de menores) têm o mesmo propósito: punir mais severamente o sujeito que, ao incidir na prática delitiva, envolva menor de idade em sua conduta. O que ocorre, na hipótese, é a aplicação do princípio da especialidade, que estabelece que a *lex specialis* afasta, nos limites de seu alcance de aplicação, a incidência da *lex generalis*.

No caso sub judice, a *lex generalis* é o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que este pune o infrator imputável a fim de proteger o adolescente de ser corrompido por praticar (ou participar de) infração penal. A *lex specialis*, evidentemente, é o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, pois tutela a mesma situação jurídica, porém em uma hipótese específica, qual seja, o envolvimento de menor (criança ou adolescente) na perpetração dos crimes previstos nos artigos 33 a 37 da Lei de Drogas (v.g., em caso de envolvimento de adolescente em crimes como o tráfico de drogas e a associação para o tráfico, aplica-se apenas a causa de aumento prevista na Lei de Tóxicos, não se cogitando do crime de corrupção de menores, sob pena de bis in idem).

Assim já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM.

OCORRÊNCIA. DUPLA PUNIÇÃO EM RAZÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. A controvérsia cinge-se em saber se constitui ou não bis in idem a condenação simultânea pelo crime de corrupção de menores e pelo crime de tráfico de drogas com a aplicação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas. 2. Não é cabível a condenação por tráfico com aumento de pena e a condenação por corrupção de menores, uma vez que o agente estaria sendo punido duplamente por conta de uma mesma circunstância, qual seja, a corrupção de menores (bis in idem). 3. Caso o delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos não esteja previsto nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas, o réu poderá ser condenado pelo crime de corrupção de menores, porém, se a conduta estiver tipificada em um desses artigos (33 a 37), pelo princípio da especialidade, não será possível a condenação por aquele delito, mas apenas a majoração da sua pena com base no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. 4. In casu, verifica-se que o réu se associou com um adolescente para a prática do crime de tráfico de drogas. Sendo assim, uma vez que o delito em questão está tipificado entre os delitos dos arts. 33 a 37, da Lei de Drogas, correta a aplicação da causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da mesma Lei. 5. Recurso especial improvido" (STJ - 6ª Turma, REsp 1622781/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/11/2016, DJe 12/12/2016).

Dessa forma, ante a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, aos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, da referida lei, afasta-se a imputação pela prática do crime de corrupção de menores (artigo 244-B da Lei nº 8.069/90).

Por fim, "(...) Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu é medida que se impõe. - A negativa da autoria formulada pelo réu, isolada e

inverossímil diante da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório (...)" (TJ-MG - APR: 10479120210774001 MG , Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 19/09/2013, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/09/2013).

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria penal, analisam-se as circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (dolo inerente ao tipo); antecedentes (o acusado é reincidente específico - Processo nº 1500049-66.2020.8.26.0583-fls. 141/142, o que será levado em consideração na segunda fase da dosimetria da pena); conduta social (nada a considerar); personalidade (nada a considerar); motivos do crime (inerentes à espécie); circunstâncias do crime (nada a considerar); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar); natureza e quantidade do entorpecente (relevantes, uma vez que se trata de 27,75 gramas de cocaína, em forma de pedras de crack, fracionadas e acondicionadas em 29 papelotes; 35,17 gramas de cocaína, acondicionada em uma pedra; e 0,56 gramas de cocaína, em forma de pedra de crack, acondicionada em um papelote, tratando-se de entorpecentes altamente viciantes e devastadores das relações sociais, não podendo o traficante de drogas menos devastadoras, por exemplo, maconha, ser equiparado ao traficante de crack, este último atuando de maneira mais devastadora para a sociedade).

Assim, em razão da natureza do entorpecente, fixo a pena base majorando-a em 1/6 (um sexto) do mínimo legal, totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria penal, presente a circunstância agravante da reincidência específica (Processo nº 1500049-66.2020.8.26.0583-fls. 141/142-arts. 61, I; 63 e 64, I, todos do Código Penal.). Assim, de acordo com o parâmetro estabelecido pelo C. STJ no HC 305.029/SP (5ª Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 25/11/2014), o reincidente específico não deve ser tratado como mero reincidente, devendo a reincidência específica ser tratada como maior gravidade. Lado outro, presente a atenuante referente à menoridade relativa do acusado (art. 65, I, CP). Compensando-se parcialmente a reincidência específica com a menoridade relativa, de rigor que, nesta fase da dosimetria da pena, seja majorada a reprimenda em 1/6 (um sexto), totalizando 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria penal, ausente qualquer causa de diminuição da pena, não se podendo cogitar na aplicação, in casu, do disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu não é primário. Aliás, é reincidente específico. Lado outro, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, porquanto o crime de tráfico de drogas envolveu a adolescente J.A.S. - 15 anos à época dos fatos (d.n. 21/07/2006 - fl. 30), razão pela qual majora-se a reprimenda à razão de 1/6 (um sexto) (art. 40, caput, Lei nº 11.343/06), perfazendo-se em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, evidenciando gravíssimo risco social e a elevada periculosidade do agente (que envolveu adolescente na empreitada criminoso), além da prática de crime gravíssimo (tráfico de drogas, in casu, de cocaína e de crack - entorpecentes altamente viciantes e devastadores das relações sociais), bem como tendo em vista tratar-se de réu reincidente específico em relação ao crime em tela e, ainda, haja vista o quantum de pena aplicado, fixo o regime fechado para o início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, alínea a, e § 3º, do Código Penal.

Pelos motivos acima, o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, do Código Penal). Também não faz jus à suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, caput, do Código Penal.

Por fim, por força do §2º do art. 387 do CPP, com a nova redação dada pela Lei nº 12.736/12, em linha de princípio, deve o juiz da esfera de conhecimento, após fixar

a pena definitiva e o regime inaugural de cumprimento da expiação, dedicar novo capítulo na sentença condenatória para a análise de eventual progressão de regime. Entrementes, o desconto imposto pela novel legislação deve ser ponderado à luz das regras insculpidas na Lei de Execução Penal, e não como mero cálculo aritmético isolado, sob pena de permitir ao condenado uma progressão de regime imprópria, ou seja, com lapsos temporais reduzidos e desconhecimento completo de seu mérito pessoal, em total arrepio às regras existentes, as quais, diga-se de passagem, não foram revogadas.

Em outras palavras, o período de detração para fins de progressão de regime prisional já na fase de conhecimento, além de corresponder às frações legalmente estabelecidas, não tem o condão de desautorizar o juiz na aferição do mérito do sentenciado, o que será verificado pelo atestado de comportamento carcerário e, em alguns casos, de parecer criminológico, notadamente quando houver necessidade de um exame mais acurado sobre o progresso de ressocialização.

Cumprir registrar que a inovação legislativa instituiu uma interação entre as jurisdições penais de conhecimento e executiva, propiciando ao magistrado da primeira etapa de cognição o reconhecimento de eventual progressão de regime prisional, desde que presentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos na lei de regência.

Ou seja, para a progressão de regime há uma série de fatores que devem ser computados. E, no presente caso, ainda que tivesse o réu cumprido o requisito objetivo (temporal), a análise de mérito, pela própria natureza e gravidade dos delitos perpetrados, não prescinde, no entender deste Magistrado, da prévia submissão de análise dos elementos subjetivos.

Sob tal argumentação, deixo de detrair o tempo de pena cumprido em sede cautelar, postergando a análise ao Juízo de Execução.

DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória, o que faço para:

- ABSOLVER o réu FELIPE DOS SANTOS CABRAL, vulgo "Cabralzinho", da imputação da prática do delito descrito artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal;
- ABSOLVER o réu FELIPE DOS SANTOS CABRAL, vulgo "Cabralzinho", da imputação da prática do delito descrito artigo 35, da Lei nº 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

- CONDENAR o réu FELIPE DOS SANTOS CABRAL, vulgo "Cabralzinho" ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, fixados estes no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso nas penas dos crimes dos artigos 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

O réu permaneceu preso durante a instrução processual e praticou crime gravíssimo, equiparado a hediondo, qual seja, tráfico ilícito de entorpecentes. A presente sentença condenatória torna ainda mais veemente o fumus boni juris necessário para a manutenção da custódia cautelar do acusado. Consoante já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

"Inaplicável, a outorga do benefício a quem já se encontra preso, em flagrante ou preventivamente, por ocasião da sentença condenatória, pois, seria incongruente que o réu preso provisoriamente em virtude de medida cautelar, viesse, ao depois de condenado, ser libertado ex-vi da lei 5.941/73. Poder-se-ia, então, dizer que ficou preso pelo menos e foi posto em liberdade pelo mais" (RHC 177 - RJ- 5! Cfm. do STJ, v.u., rel. M. Assis Toledo, DJU, de 30.10.89 - RT 504/339).

Não bastando, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar do réu, como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assim, INDEFIRO ao réu o direito de apelar em liberdade, devendo, caso queira, recorrer custodiado. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido. Transitada em julgado a sentença:

a) Notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, consoante o artigo 50, caput, do Código Penal;

b) Inclua-se o registro da condenação no Sistema Informatizado Oficial, porquanto o lançamento do nome do réu no rol dos culpados é providência desnecessária, ante a revogação do artigo 393, inciso II, do Código de Processo Penal, pelo artigo 4º da Lei nº 12.403/2011, e em vista do Provimento CGJ 33/2010, que extinguiu o Livro Rol dos Culpados;

c) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com cópia desta decisão, para suspensão de seus direitos políticos, conforme artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

d) Oficie-se ao IIRGD, comunicando-se a condenação do réu;

e) Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme artigo 105 da Lei nº 7.210/84.

f) Decreto o perdimento do dinheiro apreendido (fl. 17), porquanto evidenciado estar relacionado com o tráfico de drogas, pois ausente prova de sua lícita origem ao passo que o réu se dedica ao tráfico de drogas. Com o trânsito em julgado, encaminhe-se ofício à SENAD, comunicando acerca desta decisão e indicando a declaração de perdimento para os fins de sua destinação, ex vi do constante no artigo 63, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Lado outro, por não estar comprovado a origem ilícita ou seu envolvimento na traficância de drogas, restitua-se o aparelho celular (fl. 17) à sua proprietária. Honorários advocatícios nos termos do convênio DPE/OAB.

Custas ex legis.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Regente Feijó, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA